

1529542-52.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ FREIRE XAVIER JÚNIOR

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09 de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529542-52.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529542-52.2021.8.26.0228 PD 62/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ FREIRE XAVIER JÚNIOR

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 09 de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Promotora de Justiça Dra. Eloisa Baissardo Gagliardi, o Dr. João Ricardo Meira Amaral - Defensor Público, representando o réu José Freire Xavier Júnior, ausente injustificadamente, apesar de ciente do ato, o qual foi declarado revel, cf. r. despacho de fls. 141. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O interrogatório do réu ficou prejudicado diante de sua ausência/revelia. O Ministério Público e a Defesa não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP. Sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarada encerrada a instrução, estabelecendo-se a

realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz, o réu JOSÉ FREIRE XAVIER JUNIOR foi denunciado como incursos nas penas do artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/2006 porque, no contexto descrito na denúncia, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 02 porções de cocaína, totalizando 3,6 gramas, melhor descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 06, laudo de constatação de fls. 22/24 e laudo de exame químico toxicológico de fls., substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Devidamente notificado, o réu ofereceu defesa preliminar, sendo que a denúncia foi regulamente recebida (fls. 64/65). O réu foi devidamente citado. Foi designada audiência de instrução em julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado no final do ato. É a síntese necessária. Finda a instrução criminal, observo que os fatos narrados na inicial acusatória foram satisfatoriamente comprovados em juízo, pelo que a ação penal deve ser julgada totalmente PROCEDENTE. Inicialmente, insta esclarecer que a materialidade delitiva restou amplamente elucidada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 01, B.O de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 06, bem como pelo laudo de constatação de fls. 22/24 e laudo de exame químico toxicológico de natureza definitiva de fls., que atestaram a natureza dos entorpecentes apreendidos em poder do réu, bem como pelo relatório policial e prova oral colhida. A autoria delitiva é certa e indubitável, recaindo sobre a pessoa do denunciado. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime descrito na denúncia. Na delegacia, interrogado, o réu reservou-se ao direito de ficar calado (fls.13). Em juízo, o réu foi declarado revel. Ouvidos na fase inquisitiva, os policiais civis disseram que efetuavam diligências pelo local quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, embaixo de um viaduto. Permaneceram observando o indivíduo a distância, sendo possível verificar que o mesmo estava comercializando drogas no local, pois, conversou rapidamente com algumas pessoas, entregando a elas um objeto e recebendo outro. Resolveram efetuar a abordagem, momento em que o indivíduo tentou fugir mas foi detido. Em poder dele, foi encontrado R\$ 10,00 e 07 porções de pó branco semelhante a cocaína (fls. 11/12). Em juízo, os policiais confirmaram os fatos. Fizeram investida no local que é ponto de venda de drogas. Foram em viatura descaracterizada e viram que o réu entrega algo a terceiro, resolvera abordar. Ele tentou fugir, seu parceiro o alcançou. Com ele, havia algumas porções de cocaína e dinheiro. O depoimento dos policiais, confirmado em juízo, aliadas as circunstâncias da prisão e quantidade de estupefacientes evidencia que o réu aqui presente estava praticando o comércio espúrio de estupefacientes. Bem contextualizado, pois, o acervo probatório, com depoimento absolutamente coerente, verdadeiro e esclarecedor dos policiais, que bem retrata a veracidade da diligência e a ausência de dúvidas quanto à prática delitiva perpetrada pelo réu. Já de início ressalte-se que o fato de as testemunhas serem policiais não tem o condão de inquinar os depoimentos por eles prestados. Inicialmente, cumpre observar que as testemunhas prestaram declarações coesas, seguras e convincentes, bem expondo os fatos e a responsabilidade do réu pelo crime praticado. Ademais, suprimir o valor devido aos depoimentos única e exclusivamente pelo fato de serem policiais é, a bem da verdade, atribuir-lhes indiretamente a pecha de levianos, ao desconfiar de que mudam a versão do ocorrido no afã de legitimarem suas condutas. Ressalte-se, outrossim, que os agentes públicos, tal como as demais testemunhas, também prestam o compromisso de dizerem a verdade, estando sujeitos às penas do crime de falso testemunho (artigo 342 do Código Penal), sendo que, muitas vezes, se desmerece o depoimento dado, mas não requerem a apuração de eventual crime de falso...A bem da verdade os que sustentam o teratológico "recebimento com ressalvas" do depoimento prestado por policiais acabam por, indiretamente, colocá-los em um limbo jurídico sem qualquer razão. Isto porque, para aquela corrente, o depoimento dos policiais não é verdadeiro o suficiente para condenar e nem mentiroso o bastante para se apurar o crime de falso testemunho...Não se pode compactuar com tal forma de pensar, mormente se considerarmos que, ou bem o depoimento é verdadeiro, ou é falso! Se falso, apuraremos sua responsabilidade penal e eventualmente em seara

administrativa, desconsiderando-o como elemento de prova. Ao revés, se verdadeiro o é, deverá ser meio de prova bastante para caracterizar a responsabilidade penal. Aliás, nesta esteira, não é outro o entendimento da jurisprudência francamente majoritária: "O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida, como a narrada nesses autos" (TJSP - AC 205162-3/4 - Rel. Jarbas Mazzoni - RT733/566). Desta forma, restou evidente que a acusação se incumbiu de comprovar a prática delitiva pela prova oral coligida e pela materialidade consubstanciada na apreensão dos entorpecentes. Da fixação da pena e do regime inicial de cumprimento No tocante à pena a ser imposta, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase de fixação da pena, a reprimenda deve ser estabelecida acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade de estupefacientes, nos termos do art. 59 do CP. Já na segunda fase, observo não haver agravante tampouco atenuante. Finalmente, na terceira e derradeira fase, verifico ser possível a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da lei de drogas, em razão da expressiva quantidade de drogas que sinaliza para a criminalidade organizada. Da imprescindibilidade do regime inicial fechado Inicialmente, vale salientar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu artigo 5º, inciso XLIII, que "a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem". Assim, o constituinte preferiu elencar um rol de crimes que deveriam ser tratados com maior vigor, sendo insuscetíveis de "graça, anistia e fiança", relegando ao legislador comum a previsão de outras restrições que sejam condizentes com a peculiaridade de cada infração penal. Tais restrições foram trazidas pela Lei n.º 8.072/1990, que foi substancialmente alterada pela Lei n.º 11.464/2007. Nela se encontram taxativamente elencados os delitos que são tidos por "hediondos" - seja na sua forma tentada ou consumada -, bem como as disposições relacionadas a outros pormenores, como fixação de regime inicial de cumprimento de pena e sua progressão. Analisando-se o rol do art. 1º da Lei n.º 8.072/1990, constatamos um rol de crimes que, invariavelmente, são cometidos mediante violência e grave ameaça à pessoa. Como exemplo, temos como hediondos o homicídio, o latrocínio, a extorsão mediante sequestro, entre outros. Prestigiou-se a integridade física das pessoas e a vida humana, tida esta pela Constituição como bem jurídico primário e mais relevante, do qual decorrem os demais. Como se não bastasse, o referido delito serve como meio de subsistência de organizações criminosas evidentemente perigosas, que reiteradamente conspurcam a ordem pública e a segurança social com ataques violentos e práticas delituosas. Por meio do tráfico de entorpecentes, tais organizações conseguem somar quantias suficientemente relevantes para a compra de armas, a corrupção dos agentes estatais e para a própria manutenção do sistema criminoso, em um temerário ciclo delituoso. Mas isso não basta. Para despistar a origem espúria da pecúnia obtida através da mercancia de entorpecentes, conseguem ainda "lavar" o dinheiro obtido, depositando-o na conta de "laranjas" fielmente associados às referidas organizações criminosas. Ademais, o tráfico de entorpecentes ganha especial relevância se considerarmos os prejuízos trazidos à família do usuário, que se vê ruir aos poucos em torno da pessoa viciada, que muitas vezes dissecar todo o patrimônio visando sustentar o vício, bem como abandona a residência e passa a viver nas ruas, praticando outros delitos. Assim, diferentemente de um crime comum, no qual as consequências do delito são experimentadas apenas pelo ofendido, no tráfico de entorpecentes o crime extravasa a pessoa da vítima, expandindo seus danos também aos familiares e pessoas próximas do viciado, que sofrem e sucumbem junto ao vício do ente querido. E, mais uma vez, demonstrou-se sábio o legislador, ao estabelecer no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei n.º 8.072/1990 (modificada pela Lei n.º 11.464/2007), "a pena por crime previsto

neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado". Não há dúvidas, não há obscuridades, não há ambigüidades. O dispositivo penal é de clareza solar: o regime inicial de cumprimento de pena, para o crime de tráfico de entorpecentes, deve ser o fechado. Portanto, em sendo considerado hediondo, não resta alternativa ao juiz que não impor o regime inicial fechado, por expressa e clarividente determinação legal. Pelo exposto, o órgão ministerial aguarda o decreto de INTEGRAL PROCEDÊNCIA desta ação, a fim de que o acusado seja CONDENADO nos exatos termos propostos na denúncia, com fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena. Dada a palavra ao Dr(a). Defensor do réu, assim se manifestou: "MM. Juiz, JOSÉ FREIRE XAVIER JÚNIOR foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Encerrada a instrução a d. Acusação pleiteou a procedência da ação penal nos termos da denúncia. Vejamos a prova colhida em juízo. As testemunhas disseram ter visualizado o acusado e atitude suspeita, algo que aparentava ser venda e compra de drogas. Decidiram pela abordagem. Após pequena fuga, o acusado foi detido e revistado. Em sua posse foram localizadas porções de cocaína e certa quantia em dinheiro. Pois bem. A revelia não deve ser interpretada em desfavor do acusado. Não foram produzidas outras provas a não ser o depoimento dos próprios policiais que detiveram o acusado. Assim, e estando ausentes provas isentas acerca do ocorrido, a absolvição se impõe (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, quanto às penas requeiro: a) pena base: que seja estabelecida no piso legal ante as favoráveis circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei de Drogas e art. 59 do CP); b) agravantes e atenuantes: merece ser afastada a agravante descrita na denúncia ante a falta de nexo de causalidade entre a pandemia de covid-19 e o delito imputado ao acusado; c) causas de aumento e diminuição de pena: presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, pede-se a redução na fração de 2/3; d) regime inicial de cumprimento de pena: considerando o montante de pena aplicado, a primariedade e as favoráveis circunstâncias judiciais, pede-se que seja estabelecido o aberto; e) substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos: presentes os requisitos do art. 44 do CP, pede-se a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos; f) recurso em liberdade: ausentes requisitos para a decretação da prisão preventiva, pede-se que seja deferido ao acusado o direito de recorrer da r. Sentença em liberdade." Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. JOSÉ FREIRE XAVIER JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque em 06 de dezembro de 2021, na Rua Bresser, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, durante período de ocorrência de estado de calamidade pública, trazia consigo e guardava, para fins de venda e entrega ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções de cocaína, totalizando 3,6g, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi preso em flagrante delito por Policiais Civis e posteriormente passou a acompanhar o processo em liberdade. Recebida denúncia (fls. 64/65), o réu foi citado (fls. 105), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 109/110). O acusado foi declarado revel, ante a ausência injustificada, seja presencialmente no Fórum Criminal, ou mesmo, por via remota pelo MS Teams, embora plenamente ciente da realização da presente audiência, inclusive tendo se comprometido a participar do ato, com o apoio do setor de Assistência Social do Albergue Arsenal da Esperança onde reside (vide fls. 137 e 141). O processo seguiu à revelia do acusado, nos termos do artigo 367 do CPP, sendo realizada a instrução criminal, com a oitiva dos Policiais Civis Alidier e Eduardo. O interrogatório do acusado restou prejudicado diante de sua ausência/revelia. O Ministério Público, em sede de debates orais, pediu a condenação. A Defesa, por sua vez, pediu a absolvição. Subsidiariamente pretendeu: a) pena base no piso legal; b) o afastamento da agravante da calamidade pública; c) o redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração de 2/3; d) o regime inicial aberto; e) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos nos termos do art. 44 do CP; e f) o recurso em liberdade. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do acusado é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. de fls. 01 e seg.; pelo

B.O. de fls. 02/04; pelo A.E.A. de fls. 06; pelos depoimentos dos policiais (fls. 11/12); pelo laudo de constatação de fls. 22/24; pelo L.E.Q.T. de fls. 138/140; e pelo teor da prova testemunhal colhida em Juízo. Com efeito, os policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, ao serem ouvidos nas duas fases procedimentais, esclareceram que efetuavam diligências no local dos fatos, já conhecido por ser ponto de venda de drogas. Foi assim que avistaram o réu José Freire, sob o viaduto Bresser, passando a observá-lo. Viram que várias pessoas se dirigiram até o acusado, dele recebiam a droga após efetuar o pagamento, retirando-se em seguida. Ficou evidente que o acusado estava a comercializar drogas e resolveram efetuar abordagem. Ao notar a aproximação dos policiais, o réu correr em desabalada carreira, mas foi alcançado e submetido a busca pessoal. Na posse do réu apreenderam 07 (sete) porções de cocaína e R\$ 10,00 em dinheiro. O réu foi então conduzido ao 8º DP Brás onde foi lavrado o A.P.F.D. Enfim, esta é a prova que prepondera nos autos, não havendo qualquer negativa ou justificativa por parte de José Freire, que inclusive optou pela revelia. Destarte, diante da prova colhida, conclui-se que restou plenamente caracterizada a narco-traficância, sendo mister a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão, embora caracterizada, não tem o condão de diminuir a pena abaixo do patamar mínimo fixado. Deixo de aplicar a agravante da calamidade pública, ante a ausência de nexo causal entre a prática criminosa e a Pandemia do Covid-19. Por não ter ficado comprovado que o réu integrasse diretamente organização criminosa, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduzo a pena supra em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, CONDENO o réu JOSÉ FREIRE XAVIER JÚNIOR, RG/SP 53.679.011 e CPF 008.793.884-71, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. Na hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Faculto-lhe o apelo em liberdade. O valor em dinheiro arrecadado com o réu deverá ser revertido em favor da SENAD. A droga deve ser incinerada. Intime-se o réu revel, pessoalmente e por edital. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, saindo as partes intimadas, inclusive quanto ao prazo recursal. Autorizo xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA